

1525167-08.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... que justificou o afastamento do tráfico privilegiado. Regime fechado mantido.

4. Recurso improvido. V.U. (Apelação Criminal nº 1504424-26.2020.8.26.0320 - 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgado em 22 de março de 2022. REL. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525167-08.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525167-08.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282536/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20858569 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3686/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2282536 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2282536 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 3686/21/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS ANDRE DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA

Vistos.

CARLOS ANDRE DOS SANTOS e EVERSON YOSHIMITSU NITTA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no 15 de outubro de 2021, por volta das 10 horas, no Largo do Arouche, n.º 167, República, nesta Capital, o primeiro trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, por ocasião de calamidade pública, 30 (trinta) invólucros de cocaína, com 19,7 gramas, além da quantia de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e o segundo trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, por ocasião de calamidade pública, 20 (vinte) invólucros de cocaína,

com 13,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis municipais realizavam patrulha pelo local dos fatos quando avistaram CARLOS, EVERSON e Kelly Shield Nascimento Maia (nome social Jailson Nascimento Maia) próximos a um carrinho de lanche. Ao verem a guarnição da Guarda, os três adotaram atitude evasiva e comportamento suspeito, razão pela qual os guardas decidiram realizar a abordagem. Em revista pessoal de Kelly, foram encontradas duas porções de cocaína em seu cabelo e uma porção da mesma droga em suas partes íntimas, com peso total de 1,96 grama. Com EVERSON, foram encontradas 20 porções de cocaína, em seus bolsos e blusão. Em revista pessoal, com CARLOS, foram encontradas 29 porções de cocaína e a quantia de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em dinheiro. Formalmente interrogado, CARLOS negou a prática delitiva (fl. 10). Igualmente EVERSON negou a prática delitiva, afirmando que estava com apenas duas porções de cocaína (fl. 11). Kelly afirmou que estava com três porções para consumo próprio (fl. 9). As circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes, individualmente fracionados em pequenas porções, bem como a apreensão de dinheiro em trocados, demonstram que as drogas de CARLOS e EVERSON eram destinadas à entrega e ao consumo de terceiros. Considerando a natureza e a pequena quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, a Autoridade Policial concluiu que Kelly tinha drogas para consumo pessoal, sendo lavrado termo circunstanciado de ocorrência.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 123/126), os réus foram citados (fls. 160/163) e apresentaram resposta à acusação (fls. 173). Denúncia foi ratificada a fls. 183.

Em audiência realizada em 17 de janeiro de 2022 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus (fls. 201/206 - link)

Encerrada a instrução, requereu o Ministério Público a conversão do julgamento em diligência para a juntada do laudo definitivo das substâncias. No mérito, sustenta a procedência da ação penal. Relativamente à pena aplicável, pugna pelo afastamento da agravante, vedação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e regime inicial fechado para CARLOS e aberto para EVERSON.

A i. Defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação penal, absolvendo-se ambos os acusados com supedâneo no art. 386, incisos V ou VII, do CPP. Questiona a legalidade da prova trazida, advinda de intervenção de guardas civis metropolitanos sem atribuições para efetivar a revista e consequente prisão. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação das condutas para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pena mínima, afastamento da agravante de calamidade pública, redução por se tratar de tráfico privilegiado e fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento de eventual pena aplicada, especialmente em relação a EVERSON, primário e sem antecedentes. Por fim, aguarda a concessão do direito de recorrerem em liberdade acaso condenados.

Laudo pericial a fls. 207/209.

A fls. 211/213 foi concedida a liberdade provisória ao réu EVERSON e mantida a custódia cautelar do acusado CARLOS.

É o relatório.
Fundamento e decido.

DA PRELIMINAR

AFASTO a preliminar.

A prisão dos réus foi realizada em situação de flagrância, sendo que a lei permite que qualquer do povo a realize (art. 301 do CPP). Logo, os guardas municipais podem realizar prisão em caso de flagrante delito.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Preliminar. Arguição de nulidade das provas. Alegação de que os guardas municipais que não estariam investidos de função reservada à Polícia. Realização de busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Justa causa para a medida. Busca necessária em contexto de preservação da integridade física dos guardas. Ilegalidade afastada. Precedentes. 2. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pela prova técnica. Autoria certa. Relatos convergentes dos guardas civis narrando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Versão inconsistente apresentada pelo réu. Destinação comercial comprovada. 3. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Reincidência comprovada que justificou o afastamento do tráfico privilegiado. Regime fechado mantido. 4. Recurso improvido. V.U. (Apelação Criminal nº 1504424-26.2020.8.26.0320 - 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgado em 22 de março de 2022. REL. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). (STJ-HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015) No caso dos autos, os guardas municipais estavam em patrulha pelo local dos fatos, que é uma praça pública municipal, conhecido como ponto de drogas e prostituição, e os réus, ao avistarem a viatura, adotaram atitude evasiva e comportamento suspeito, razão pela qual os guardas decidiram realizar a abordagem e, ao revistarem os acusados, com eles foi encontrada a droga apreendida. Como traziam a droga consigo para fins de mercância, o estado de flagrância era evidente, nada havendo de ilegal na conduta dos guardas municipais.

Os guardas municipais estavam desempenhando seu mister constitucional, qual seja, zelando pelo patrimônio municipal, e, devido à situação de flagrância acima narrada, efetuaram a prisão dos acusados.

NO MÉRITO.

A denúncia PROCEDE.

1) DA MATERIALIDADE.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/54), Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 26/27), Laudo de Constatação (fls. 48/51), Exame químico-toxicológico (fls. 207/209) e pela prova oral colhida em juízo (fls. 201/206).

2) DA AUTORIA.

A autoria restou devidamente comprovada.

Interrogado na delegacia (fls. 13), o réu CARLOS ANDRE DOS SANTOS limitou-se a dizer que é vendedor e que não estava com drogas.

Em juízo, o réu CARLOS ANDRÉ disse que possui outros dois processos por roubos e um terceiro por falsidade ideológica; que trabalhava como autônomo/ ambulante; que não é usuário de droga; que não estava traficando; que estava passando no local dos fatos e que foi abordado; que o dinheiro que estava no bolso era fruto do seu trabalho como ambulante; que devido a sua reincidência foi levado para a delegacia; que não conhece o corréu Everson.

Interrogado na delegacia (fls. 14), o acusado EVERSON YOSHIMITSU NITTA declarou que faz programas na região dos fatos e que trazia apenas duas porções de Cocaína.

Em juízo, o réu EVERSON YOSHIMITSU disse que nunca foi preso ou processado antes; que é usuário de cocaína; que estava na "Rua do Arouche" fazendo programa no local; que desconhece o corréu Carlos; que não é traficante; que tinha 2 porções de cocaína e R\$ 56,00 em dinheiro; que foi abordado e evado para a delegacia.

Ouvido em solo policial, a testemunha FRANCISCO SLANA HIDALGO, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, asseverou que estavam em patrulhamento na região do Largo do Arouche, quando avistaram três indivíduos próximos a um carrinho de lanche. Kelly estava mais ao centro perto do carrinho, e os dois rapazes mais afastados. Ao verem a guarnição da Guarda, os três empreenderam atitude evasiva e comportamento suspeito, razão pela qual, resolveram proceder à abordagem. Na abordagem, com Kelly, em seu cabelo, encontraram duas porções de Cocaína, e mais uma em suas partes íntimas. Com Everson, em seus bolsos e blusão, encontraram 20 porções de Cocaína. Com Carlos, encontraram 29 porções de Cocaína e mais de 130 reais em dinheiro.

Em juízo, FRANCISCO HIDALGO afirmou que abordaram os réus no Largo do Arouche e com eles foi encontrada a droga apreendida; que estava em patrulhamento e com eles estavam em atitude suspeita, aglomerados, quando viram a viatura, se dispersaram; que os réus estavam com cocaína; havia três pessoas, com os dois réus havia grande quantidade de cocaína; que fez busca pessoal nos réus; que foi encontrado aproximadamente vinte "substâncias" embaladas individualmente com cada, que se tratava de cocaína; que havia dinheiro com um deles, o réu Everson; que havia várias pessoas no local dos fatos e todas elas foram abordadas; que somente os réus estavam com grande quantidade de cocaína; que havia uma terceira pessoa com pouca

quantidade de drogas, que foi conduzida também à delegacia.

Por sua vez, a testemunha PAULO SERGIO PERES ULIAN, também GUARDA CIVIL MUNICIPAL, afirmou em solo policial que se encontravam em patrulhamento na região do Largo do Arouche, que é local de tráfico de entorpecentes, quando avistaram três indivíduos próximos a um carrinho de lanche. Kelly estava mais ao centro perto do carrinho, e os dois rapazes mais afastados. Ao verem a guarnição da Guarda, os três empreenderam atitude evasiva e comportamento suspeito, razão pela qual, resolveram proceder à abordagem. Na abordagem, com Kelly, em seu cabelo, encontraram duas porções de Cocaína, e mais uma em suas partes íntimas. Com Everson, em seus bolsos e blusão, encontraram 20 porções de Cocaína. Com Carlos, encontraram 29 porções de Cocaína e mais de 130 reais em dinheiro.

Em juízo, PAULO SERGIO afirmou que tem ordem de serviço para realizar ronda no local dos fatos, que se tratar de uma praça municipal, tendo em vista que se trata de ponto de prostituição e venda de entorpecente; que havia uma terceira pessoa com os réus, um transgênero, o qual também portava entorpecentes, mas para consumo pessoal; que foi encontrada grande quantidade de drogas, cocaína, com os dois acusados; que a droga estava embalada em porções individuais; que havia dinheiro também com um deles; que além dos réus abordaram várias pessoas no dia do evento; que somente os réus tinham drogas.

Pois bem.

De um lado, temos os depoimentos seguros e coesos de dois funcionários públicos isentos, sem qualquer interesse em prejudicar os réus, afirmando que ao abordá-los no local dos fatos, em revista pessoal, com o réu EVERSON foram encontradas 20 porções de cocaína em seus bolsos e blusão e com o acusado CARLOS foram encontradas 29 porções de cocaína e a quantia de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em dinheiro.

A versão trazida pelas testemunhas guardas civis foi corroborada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 26/27, Laudo de Constatação (fls. 48/51) e pelo Exame químico-toxicológico (fls. 207/209). Não há sequer indícios de parcialidade no depoimento das testemunhas.

Como já pacificado na jurisprudência, os depoimentos de testemunhas que são funcionários públicos integrantes das forças policiais e congêneres, como os guardas municipais, são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, estando em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados, como já dito, pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório.

Neste sentido entende o STJ:

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

No mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo e guardar porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Apreensão do entorpecente em poder do acusado. Depoimentos de

guardas municipais que efetuaram a prisão. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0000704-48.2018.8.26.0530; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020)

TRÁFICO. Nulidade da prisão efetuada por Guardas Municipais. Ausência de legitimidade dos Guardas Municipais para realização de busca pessoal. Ilicitude das provas colhidas. Prisão em flagrante que pode ser realizada por qualquer pessoa do povo. Art. 301 do CPP. Nulidade não reconhecida. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito. Depoimentos de guardas municipais. Inexistência de contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. Ausência de dúvida que justifica o decreto condenatório. Condenação mantida. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Acusado reincidente. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado justificado pela reincidência - Recurso parcialmente provido (voto nº 41452). (TJSP; Apelação Criminal 1500200-65.2019.8.26.0551; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais ou outro agente público que tenha efetuado a prisão, e, no caso dos autos, a versão dos réus restaram completamente isolada, nada apresentando de concreto capaz de ilidir as declarações dos guardas municipais, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO

MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NULIDADES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à caracterização do delito. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIMES PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína) em poder dos réus, a forma em que estava acondicionadas (individualmente fracionados em pequenas porções), a apreensão de dinheiro em trocados, o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido pelos guardas municipais), bem como a falta de comprovação pelos réus de exercício de atividade laboral formal ou informal lícita, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo dos agentes dirigia-se especificamente à mercância, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Ressalta-se que as condutas dos acusados narradas na denúncia foram corroboradas pelas provas carreadas nos autos.

Já a versão dos réus, ao revés, não se sustenta.

Carlos limitou-se a dizer que não estava com drogas e que o dinheiro com ele encontrado era fruto de su trabalho como autônomo, contrariando, assim, todas as provas dos autos.

Everson, por sua vez, admitiu que estava com duas porções de cocaína, porém, afirmou que é apenas usuário, porém, a quantidade de drogas que ele trazia quando foi abordado em local de ponto de droga, 20 invólucros contendo o total de 13,3 gramas de cocaína, tornam as suas palavras insuscetíveis de crédito, não sendo possível acolher a tese defensiva de desclassificação do delito.

Saliento, por oportuno, que para dar crédito à versão dos acusados teríamos que considerar o absurdo: dois funcionários públicos, no exercício do seu mister, carregando consigo 34,96 gramas de cocaína apenas com o fito de forjar flagrante em detrimento de transeuntes. Portanto, cristalino que a versão dos réus não são dignas de crédito.

Em suma, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "J" DO CP.

AFASTO. Ausente demonstração concreta de que os réus se valeram do contexto da pandemia da Covid-19 para a prática do crime.

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois de exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 499).

In casu, não se vislumbra como o réu poderia ter se aproveitado da situação de calamidade pública (pandemia da COVID) para cometer o delito em questão. Não basta que o crime seja cometido durante o estado de calamidade, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, o nexo de causalidade entre a situação causada pela pandemia (Covid-19) e a prática do crime cometido pelos réus, sob pena de responsabilização objetiva.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo afastando a agravante em diversos delitos:

(...) In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a incidência da agravante do artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, foi reconhecida sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte das vítimas, vale dizer, não consta nos autos o nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente. Não se demonstrou que, em razão do estado de calamidade pública, a conduta delitiva gerou maior incapacidade ou dificuldade de defesa das vítimas, apenas consta da prova pré-constituída que o paciente executou o delito, enquanto as vítimas haviam estacionado o caminhão para fazer a entrega de cigarros da empresa Souza Cruz. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente. Mutatis mutandis: HC 632.019/SP, Quinta Turma, minha relatoria, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021. (...)" (STJ: Habeas Corpus nº 633443/SP, julgado em 24/02/2021);

"Furtos qualificados - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação, que sequer foi Impugnada - Rompimento de obstáculo e escalada não Comprovados - No presente caso, era necessário o laudo pericial para comprovar as qualificadoras Básicas tornadas ao piso - A condenação utilizada como maus antecedentes é apta a gerar reincidência - Tal condenação somente deve ser valorada na segunda etapa - Respeito ao sistema trifásico - Impossibilidade de utilização dos supostos antecedentes criminais para valorar a personalidade e/ou conduta social do réu, por serem circunstâncias distintas - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer os delitos - Integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão Espontânea - Mantido o redutor da tentativa no grau mínimo - Majoração decorrente do crime continuado mantida em 1/6 - Todos os

requisitos do artigo 71 do CP estão presentes, assim como aqueles consagrados pela jurisprudência - Regime semiaberto mantido, face à quantidade de pena aplicada e à reincidência Inviabilidade de substituição por restritivas de direitos, pois a reicidiva se deu pela prática do mesmo delito" (TJSP: AP nº 1507190-37.2020.8.26.0228, 12^a Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amable Lopez Soto, julgado em 14/04/2021); "A agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal foi compensada com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, de qualquer forma, seria o caso de se acolher o seu afastamento, eis que não há nos autos comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes, desarrazoada a aplicação automática da agravante, sem comprovação do nexo de causalidade, sob pena de responsabilização objetiva" (TJSP: AP nº 1500895-81.2020.8.26.0616, 7^a Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 14/04/2021).

A questão restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consoante orientação constante da Jurisprudência em Tese Edição 180:

(...)5 - A incidência da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da covid-19 para a prática do crime. (HC 660930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021; AgRg no HC 677124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; AgRg no HC 655924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; HC 679504/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2021, publicado em 08/10/2021; HC 698646/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2021, publicado em 08/10/2021; HC 680735/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1^a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2021, publicado em 08/10/2021).

No mais, não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA.

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, apresenta pena em abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.
CORRÉU CARLOS ANDRE DOS SANTOS.

1^a FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

Em razão disso, não vislumbro circunstância judicial desfavorável.

Diante desse quadro, a pena-base permanece no mínimo legal.

2^a FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

O réu é reincidente (fls. 55/63).

Assim, em razão dessa circunstância agravante, majoro a pena em 1/6, chegando-se à pena de 5 anos e 10 meses e 583 dias multa.

3^a FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, já que o acusado é reincidente, não fazendo jus ao benefício.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão mais o pagamento de 583 dias-multa no piso unitário legal.

VALOR DA MULTA.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

REGIME PRISIONAL.

A redação dada ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 11.464/07 estabelecendo a obrigatoriedade de cumprimento inicial fechado nos casos de condenação pelo delito do artigo 33 da Lei Antidrogas foi declarada, por maioria de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 27/06/2012.

Não obstante, tendo em vista que o condenado é reincidente, nos termos do art. 33, §2º, "b" do CP, não faz jus ao regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena., iniciando, portanto, no REGIME FECHADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Em razão da pena aplica, também não faz jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

CORRÉU EVERSON YOSHIMITSU NITTA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

Em razão disso, não vislumbro circunstância judicial desfavorável.

Diante desse quadro, a pena-base permanece no mínimo legal.

2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Em razão do disposto no artigo 33, § 4º da Lei Antitóxicos, sendo o réu primário, com bons antecedentes e não havendo provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas com habitualidade e integre organização criminosa, reduzo a pena em 1/3.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 03 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 333 dias-multa no piso unitário legal.

VALOR DA MULTA.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da

infração (TACrSP, RT 628/338).

REGIME PRISIONAL.

Tendo em vista que a redação dada ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 11.464/07 estabelecendo a obrigatoriedade de cumprimento inicial fechado nos casos de condenação pelo delito do artigo 33 da Lei Antidrogas foi declarada, por maioria de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 27/06/2012, e, ainda em atenção ao que restou decidido no HABEAS CORPUS Nº 596.603/SP do Colendo STJ, a pena do crime de tráfico terá regime inicial ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Tendo o delito sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, e, considerando que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual substituo a pena corporal do réu por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada na fase de execução, e outra consistente no pagamento de prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Nesse sentido:

"PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, foi declarada inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena - habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a reprimenda no patamar de 4 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal" (STF, HC 125.188/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016).

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Decisão do STJ que se limitou a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem sem adentrar o mérito. Supressão de instância. Superação. 4. Regime inicial fechado. Deficiência de fundamentação. Constrangimento ilegal configurado. 5. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais" (STF, HC 133.617/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para o fim de:

A) CONDENAR o réu CARLOS ANDRE DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa no piso unitário legal.

Mostra-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva do réu CARLOS, pois não se pode olvidar da gravidade do delito, da alta pena aplicada, da ausência de comprovação de exercício de trabalho lícito pelo réu, da sua habitualidade na prática criminosa (reincidente) e mormente diante da presente sentença condenatória.

Recomende-se que permaneça no local em que se encontra detido.

B) CONDENAR o réu EVERSON YOSHIMITSU NITTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 333 dias-multa no piso unitário legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada na fase de execução, e outra consistente no pagamento de prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

O réu EVERSON poderá recorrer em liberdade desta sentença.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade que defiro neste ato em razão da defesa patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA

Nos termos do art. 50-A da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Determino o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA